

1500852-53.2021.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... se justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido: Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Centro - CEP 11750-000, Fone: (13) 3455-3629,

Peruíbe-SP - E-mail: peruibe2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500852-53.2021.8.26.0441 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Data da Audiência:

03/03/2022 às 15:00h

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RIBEIRO MOREIRA e outro

Vistos.

GABRIEL RIBEIRO MOREIRA e LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, c.c. artigo 61, inciso, II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Alan Kardec, nº 1270, Condomínio Três Marias, nesta cidade e comarca de Peruíbe, de comum acordo e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, 01 fone de ouvido marca JBL, 03 notebook/Laptop marca Samsung/multilaser/HP, 01 notebook/laptop marca Apple, 01 videogame portátil marca Xbox, 02 anéis e 01 brinco de ouro, 01 joia em prata, 01 aparelho de telefone celular marca Apple, 01 aparelho de telefone celular marca Xiaomi, 01 aparelho de telefone celular marca Samsung, 01 peça de roupa, além das quantias em espécie de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) e 25 (vinte e cinco) euros, pertencentes à vítima Glaucia Regina Arranjo, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 110/111), os réus foram regularmente citados (fls. 168 e 171) e apresentaram resposta à acusação (fls. 174/175 e 206/208), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 211/212).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha da acusação, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais,

requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente fosse a pena fixada no mínimo.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece PARCIAL acolhimento, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pela confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria em relação ao réu GABRIEL, incidindo causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.

Quanto ao réu LUCIANI, como se verá a seguir, a pretensão não procede.

A materialidade do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, caput, § 2º, inciso I, do Código Penal, foi devidamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/32, 37/38), e pela prova oral produzida em juízo. Por seu turno, a autoria delitiva do réu GABRIEL é igualmente comprovada, especialmente pelo seu reconhecimento em solo policial e em Juízo por parte da vítima, bem como pela confissão. Já quanto ao réu LUCIANO, não há provas bastantes para a condenação.

Eis a síntese da prova oral produzida.

Em ato de reconhecimento, a vítima reconheceu a pessoa com a placas 5 (Gabriel) como autor do delito, sem hesitação. Após alguma hesitação, e após os indivíduos sorrirem, apontou a pessoa com a placa 3 (Luciano). Explicou em Juízo que estavam jantando quando eles ingressaram na casa. Um deles ficou com a depoente no andar de baixo da casa enquanto o outro subiu. Eles perguntaram se tinha cofre, respondeu que não tinha. Ficaram todos virados para a parede da cozinha. Ele perguntava se tinha mais alguém na casa, se ia chegar alguém, se havia dinheiro. Ficaram nessa situação por cerca de 1 hora e 20 minutos. Após, eles pediram para que todos subissem e sentassem em um quarto, com a cabeça baixa. Eles já tinham separado as coisas. Foi chamada por um deles, pois ele tinha achado um "cofrinho" no quarto de seu filho, questionando o porquê da depoente ter dito que não havia dinheiro na casa. Explicou e buscou acalmá-lo. Eles foram embora e disseram para aguardar 20 minutos até que eles descessem. Eram apenas duas pessoas. Não lembra se eles estavam de máscara ou sem. O que subiu estava com uma camisa no rosto. O número 5 subiu e o número 3 ficou na parte térrea. Registraram a ocorrência. Foi chamada à delegacia e reconheceu seus pertences, como roupas, cremes, aparelho celular. Recuperou parte dos seus pertences. Reconheceu os réus na delegacia, o Gabriel pessoalmente e o Luciano por fotografia, em um primeiro momento. No celular do Gabriel tinham muitas fotos dos réus juntos. Reconheceu o Luciano pelas fotos em que ele estava junto com o Gabriel. Depois, reconheceu pessoalmente, em outra oportunidade, o Luciano. No momento dos fatos, estava junto com seu sobrinho, de 9 anos de idade, e seus filhos de 8, 12 e 13 anos de idade. Os roubadores não foram agressivos e não cometeram agressão física. Depois dos fatos, passou 15 dias na casa de sua mãe. Seus filhos tiveram pesadelos por longo tempo e quiseram voltar a dormir no quarto dos pais. Modificaram a rotina. Ficam com a casa toda trancada e ficam mais atentos. Nada mais é como era antes. Teve um prejuízo de R\$ 30 a 35 mil. O condomínio tem vigia e segurança, mas eles entraram pelo muro lateral. Os guardas fazem ronda de bicicleta ou a pé, mas não perceberam nada. Uma vizinha também passou pela casa com um cachorro mas também não percebeu.

O policial civil Anderson Carlos Lomenzo Buono relatou em Juízo que estavam ocorrendo diversos furtos e roubos dentro dos condomínios de Peruíbe. Especialmente o caso dos autos, obtiveram informações durante trabalhos de campo, que levaram a um dos réus. Em diligência de busca e apreensão na casa do Gabriel, com ordem judicial, foram recepcionados por ele, que admitiu que tinha realizado um furto. Havia diversos objetos na casa dele, entre roupas, joias e outras coisas. Ele confessou que tinha ingressado para fazer um furto, mas a vítima apareceu e os fatos se tornaram roubo, pois houve ameaça. Entraram em contato com a vítima do roubo e ela compareceu na delegacia, onde realizou o reconhecimento pessoal. Informalmente, o Gabriel esclareceu que estava com o Luciano. Em um primeiro momento, a vítima reconheceu o Luciano por fotografia. Posteriormente, o Luciano foi preso e a vítima compareceu novamente na Delegacia, reconhecendo-o.

Informalmente, o Luciano confessou o roubo. Depois da prisão dos réus, a estatística de roubos na região quase zerou. Depois, o Gabriel ainda pediu para que seus parentes disponibilizassem os demais objetos furtados para a Polícia. O Gabriel informou que simulou estar armado, pois sua pretensão era furtar, mas a vítima apareceu no local. A maior parte dos objetos não foi recuperada. Não sabe quanto tempo eles ficaram dentro do imóvel. Participou da prisão do Luciano. O réu GABRIEL, ouvido em Juízo confessou os fatos. Aconteceu mesmo. Foi praticar um furto, mas quando viu que tinha gente simularam que estavam armados com um chinelo por baixo da camisa. O Luciano não estava. Praticou o crime junto com o Júnior. Devolveu todos os bens aos policiais e ao marido da vítima. O réu LUCIANO, ouvido em juízo, negou os fatos. Não estava no local. Estava em sua casa quando a polícia ingressou em sua casa e lhe acordou. Eles perguntaram se tinha objeto de crime em sua casa, respondeu que não. Estava trabalhando. Conhece o Gabriel, mas não participou do crime. Foi ameaçado pela Polícia. Ameaçaram de prender sua mulher. Disse que assumiria o fato para livrar sua mulher. Apanhou na delegacia. Assumiu os fatos na delegacia após ter sido ameaçado e apanhado. A confissão prestada em Juízo por Gabriel, de espontaneidade inquestionável, não destoa do restante da prova produzida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi descrito pormenorizadamente pela vítima em Juízo, ademais ratificada com firmeza em audiência a identificação afirmada na fase policial em reconhecimento direto por ocasião da prisão de Gabriel (fls. 40). É certo que o depoimento dos policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

“É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 e-book).

O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485.543 SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que o policial ouvido alterasse a verdade quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a ele prestada por ocasião da abordagem de GABRIEL.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunha se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

É cediço que a apreensão de boa parte dos bens objeto de roubo em poder do acusado Gabriel gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

No que toca ao reconhecimento, é de se ver que a vítima, comparecendo ao local da prisão do réu, identificou-o de modo direto, espontâneo, afirmando com convicção tratar-se do agente. Em audiência, reconheceu o réu novamente, sem hesitação.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro do réu ratificado em Juízo, bem assim pelo relato da testemunha e pela confissão do acusado, de tal sorte que materialidade e autoria do delito, em relação ao Gabriel, encontram-se perfeitamente comprovadas.

A participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

É certo que a consumação foi atingida, porque conquistada e aproveitada posse desviada da res, retirada da vítima e levada pelos agentes quando tomaram rumo sem que ninguém os perturbasse, resultando a subsequente recuperação parcial da res de casual intervenção policial bem-sucedida, já inserida em desenrolar causal autônomo.

Já com relação a LUCIANO, a o acervo probatório não traz a segurança necessária à condenação. Da análise detida dos autos, verifica-se que não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar a condenação.

Nesse ponto, observo que, em juízo, a vítima disse ter feito reconhecimento pessoal de Luciano na delegacia. O auto respectivo, contudo, não veio aos autos. Há nos autos somente o documento de fls. 41, que consiste em auto de reconhecimento fotográfico de Luciano.

Em juízo, a vítima informou que reconheceu Luciano na Delegacia a partir de fotos dele no celular do Gabriel. Disse que havia várias fotos de ambos juntos no celular de Gabriel.

Evidente que a vítima, ao ver ambos juntos no celular de Gabriel, tende a reconhecer Luciano como a pessoa que estava junto com Gabriel no dia dos fatos. A partir do momento em que vê essas fotos, a memória da vítima está comprometida, porque passa a vincular a pessoa vista nas fotos com o roubador. Tende, portanto, a reconhecê-lo também em outras oportunidades, não necessariamente por ter sido a pessoa que estava no dia do roubo, mas por tê-la visto nas fotografias do celular, mantendo-a em sua memória.

Situações assim tornam prejudicada a diligência de reconhecimento feita em sede policial e, conseqüentemente, também aquela realizada em juízo. O reconhecimento fotográfico é, por si só, problemático, porque suscita uma série de dúvidas acerca de sua validade, visto que não tem a mesma natureza, tampouco, por óbvio, a mesma idoneidade do reconhecimento pessoal.

Há intensa controvérsia quanto à validade do reconhecimento fotográfico como fundamento do édito condenatório. De todo modo, para aqueles que defendem a validade deste meio de prova, exige-se respaldo também em outros elementos dos autos. Ou seja, o reconhecimento fotográfico não é bastante para ensejar a condenação, embora sirva como reforço argumentativo, desde que encontre ressonância em outros fundamentos.

Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

No caso dos autos, a única prova concreta que se produziu acerca da participação de

Luciano, além do reconhecimento fotográfico feito em solo policial, foi o reconhecimento em juízo, evidentemente enviesado pela memória que a vítima já tinha em decorrência do contato prévio com a fotografia do réu.

Note-se, ademais, que o reconhecimento em juízo, diferentemente do que aconteceu em relação ao réu Gabriel, não foi firme. A princípio, a vítima se mostrou hesitante. Pediu que todas as pessoas colocadas em fila sorrissem, para somente então apontar o réu Luciano, ainda que sem a mesma firmeza com que apontou Gabriel.

Nenhum bem objeto do crime foi encontrado na posse de Luciano. A testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, razão pela qual não pode apontar com segurança sua participação no delito.

O réu negou de forma veemente a participação no delito, insistindo com firmeza em sua inocência. O corréu Gabriel, ouvido em juízo, disse que Luciano não participou do roubo, mas sim uma pessoa de alcunha "Júnior", que não foi identificada.

O prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO

PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 - e-book).

Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

Assim, pelo que se expôs acima, é caso de absolvição do réu LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS.

Por outro lado, com relação ao réu GABRIEL, a condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para ambos os delitos. A culpabilidade do agente não destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa. Os antecedentes serão apreciados a seguir.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 261/263, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado, pelo que, atendido o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a base inalterada.

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, apontada na denúncia. Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo coronavírus, não se observa que essa circunstância tenha sido relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa. Tratando-se, no caso, de circunstância meramente acidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e tampouco foi impactada pela conduta da ré, não se justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido: Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 -

Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

Visto que o delito foi praticado em concurso de agentes, incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, no patamar de um terço, indo as penas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade concreta e objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz, além da reincidência do acusado.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Na falta de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado,

estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça. Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, em razão do montante fixado.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu GABRIEL RIBEIRO MOREIRA, por infração ao artigo 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia. Dada a solução de mérito adotada, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado GABRIEL RIBEIRO MOREIRA no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, acentuado o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 03 de março de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Juiz Substituto